

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제2절 항소의 제기>

I. 항소제기의 방식

1. 항소장의 제출

- 항소는 제1심 판결을 내린 법원에 항소장을 제출함으로써 제기한다. 이를 항소장제출주의라고 하며, 항소심 법원이 아닌 원심법원에 제출해야 한다는 점이 특징이다. 항소장에는 당사자와 법정대리인, 제1심 판결의 표시와 그 판결에 대한 항소의 취지를 반드시 적어야 한다.

2. 항소기간의 준수

- 항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 제기해야 한다. 이 기간은 불변기간이므로 당사자가 책임질 수 없는 사유로 지킨 경우를 제외하고는 연장이 불가능하다. 판결서 송달 전에도 항소를 제기할 수 있으나, 판결이 선고되기 전의 항소제기는 부적법하다.

3. 인지의 첨부 및 송달료 납부

- 항소장에는 민사소송 등 인지법이 정하는 바에 따라 제1심 인지액의 1.5배에 해당하는 인지를 붙여야 한다. 또한 항소장 부분의 송달 및 재판 절차 진행을 위한 송달료를 예납해야 한다.

II. 재판장의 항소장심사권

1. 원심재판장의 항소장심사권

- 항소장이 접수되면 원심법원의 재판장은 항소장의 필수 기재사항 누락 여부와 인지 첨부 여부를 심사한다. 만약 흠결이 있다면 상당한 기간을 정하여 보정을 명하며, 보정하지 않을 경우 명령으로 항소장을 각하한다. 또한 항소기간을 도과하였음이 명백한 경우에도 원심재판장이 항소장각하명령을 내린다.

2. 항소심재판장의 항소장심사권

- 원심재판장의 심사를 거쳐 기록이 항소심 법원에 송달되면, 항소심 재판장 역시 동일한 권한을 가진다. 원심에서 발견하지 못한 흠결이 있거나 보정 명령을 이행하지 않은 경우 항소심 재판장은 명령으로 항소장을 각하한다.

3. 불복방법

- 재판장의 항소장각하명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다. 이는 판결이 아닌 명령에 의한 재판이므로 독립하여 다룰 수 있는 기회를 보장하는 것이다.

III. 항소의 취하

1. 의의[민소법 제393조]

- 항소의 취하란 항소제기에 의해 개시된 항소심 절차를 항소인이 스스로 종료시키기 위해 행하는 소송행위이다. 항소를 취하하면 소송은 항소제기가 없었던 상태로 돌아가며 원심판결이 확정된다.

2. 요건

- 항소취하는 항소심의 종국판결이 있기 전까지 가능하다. 소의 취하와 달리 상대방의 동의를 필요로 하지 않는데, 이는 피항소인에게 원심판결을 유지하는 것이 통상 불리하지 않기 때문이다. 다만, 항소취하는 서면으로 하는 것이 원칙이나 변론기일 등에서는 말로 할 수도 있다.

3. 효과

- 항소취하가 있으면 항소심 절차는 소급적으로 종료된다. 이로써 제1심 판결은 항소기간 만료 시에 소급하여 확정된 것으로 간주된다. 취하한 자는 다시 동일한 항소를 제기할 수 없다.

4. 항소취하간주

- 당사자 쌍방이 변론기일에 2회 불출석하거나 기일에 출석하더라도 변론하지 아니한 경우, 1월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 지정된 기일에 다시 쌍방 불출석하면 항소를 취하한 것으로 본다. 이를 상소심의 필요적 기일지정 및 취하간주 제도라 한다.

5. 항소취하의 합의

- 당사자 사이에 항소를 취하하기로 하는 소송외의 합의가 가능하다. 이러한 합의가 있음에도 항소를 유지할 경우 법원은 소권의 부존재를 이유로 항소를 각하해야 한다.

6. 항소의 일부취하의 가부

- 수개의 청구 중 일부에 대해서만 항소를 취하하거나, 청구의 수량적 일부에 대하여 취하하는 것은 허용된다. 다만, 주문이 불가분인 경우에는 일부취하가 논리적으로 불가능할 수 있다.

IV. 부대항소

1. 의의[민소법 제403조]

- 부대항소란 항소심 절차에 편승하여 피항소인이 항소인에 대하여 자기에게 유리하게 항소심판의 범위를 확장하기 위해 제기하는 공격적 소송행위이다. 스스로 항소권을 포기하였거나 항소기간이 지난 경우에도 상대방의 항소에 기해 제기할 수 있다.

2. 인정취지

- 당사자 일방만이 항소한 경우 상소불이익변경금지의 원칙에 의해 피항소인은 원심판결보다 유리한 판결을 얻을 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 상대방이 항소를 제기하여 판결의 확정을 막은 이상, 피항소인에게도 불복의 기회를 주어 형평을 기하려는 데 목적이 있다.

3. 법적 성질

- 부대항소는 독립된 상소가 아니며 항소심 절차에 종속된 특수한 소송행위이다. 따라서 주된 항소가 취하되거나 각하되면 부대항소도 원칙적으로 효력을 잃는다.

4. 요건

- 부대항소는 항소심 변론종결 전까지 제기해야 한다. 주된 항소가 적법하게 살아 있어야 하며, 피항소인이 항소인을 상대로 제기해야 한다. 항소권의 포기나 항소기간 도과 후에도 가능하며, 주된 항소의 범위를 넘어서는 것도 허용된다.

5. 방식

- 항소에 관한 규정을 준용하므로 부대항소장을 제출하는 것이 원칙이다. 부대항소장에는 부대항소의 취지와 범위를 명시해야 하며, 주된 항소장과 마찬가지로 인지를 붙여야 한다.

6. 효과

- 부대항소가 제기되면 항소심의 심판 범위는 부대항소인이 불복한 범위까지 확장된다. 법원은 주된 항소와 부대항소를 함께 심리하여 하나의 판결을 내린다. 만약 주된 항소가 취하되면 부대항소는 효력을 잃는 것이 원칙이나, 항소기간 내에 제기된 부대항소는 독립된 항소로 보아 주된 항소의 취하와 상관없이 존속한다.

V. 결론

- 항소의 제기는 제1심 판결의 확정을 차단하고 사법 정의를 실현하기 위한 엄격한 절차적 요건을 필요로 한다. 항소장 제출부터 재판장의 심사, 당사자의 의사에 의한 취하에 이르기까지 모든 과정은 소송의 신속과 당사자의 방어권 보장이라는 균형 위에서 작동한다. 특히 부대항소 제도는 상소불이익변경금지 원칙의 예외로서 당사자 간의 실질적 형평을 도모하는 중요한 수단이 된다. 이러한 제반 절차를 통해 항소심은 제1심의 불완전성을 보완하고 실제적 진실에 부합하는 중국적인 권리 확정을 지향한다. 따라서 소송 당사자는 각 단계의 법적 요건과 효과를 명확히 숙지하여 자신의 소송상 지위를 전략적이고 적법하게 관리해야 할 것이다.